

1500134-27.2019.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... foi encontrado; local palco frequente de tráfico; foi próximo a um ginásio e havia pessoas no local; trata-se de um local movimentado; o réu já era conhecido por tráfico, embora tenha negado.

A testemunha Paulo Roberto Coelho Jacinto, também policial, no inquérito, prestou depoimento no mesmo sentido. Embora sob o crivo do contraditório tenha dito não se recordar dos fatos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Centro, Santa Cruz Das Palmeiras - 13650-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500134-27.2019.8.26.0538

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2078363, 422/19/210, 2078363, 422/19/210, 2078363, 422/19/210, 2078363, 422/19/210, 2078363/2019, 4193971, 422/2019

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Everton Aparecido Garcia

Ao(s) 10 de agosto de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, sendo realizada, por meio virtual, via videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI, comigo, Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, estiveram presentes na teleaudiência:

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). SERGIO HENRIQUE MARINO, DD(a). Promotor(a) de Justiça; A(O)(s) ré(u)(s) Everton Aparecido Garcia, acompanhado(a)(s) de sua(s) Defensor(es) (a)(s) nomeado(a)(s) Dr(es)(a)(s). Conceição Donizetti Fogatti Galimbertti OAB 250735/SP;

A(s) testemunha(s) de comuns Fabio Alexandre Andre e Paulo Roberto Coelho Jacinto.

Após, antes do início dos trabalhos, o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa não solicitou(ram) comunicação privada com a(o)(s) ré(u)(s), em virtude de ter havido conversa prévia em lugar diverso e/ou ausência da(o)(s) ré(u)(s) na audiência virtual. Pelo Ministério Público, nada foi requerido.

Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz foi dito: "Nos termos da resolução 465

de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, zelando pela adequada identificação e vestimenta que a solenidade requer, alerta ao(a)(s) Advogado(a)(s) e o(s) membro(s) da Defensoria Pública e do Ministério Público da necessidade de utilização de terno ou toga, permanecendo com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado durante toda sessão."

Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) Fabio Alexandre André (início do vídeo próprio) e Paulo Roberto Coelho Jacinto (06:56 do mesmo vídeo).

Em seguida, o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa solicitou(ram) comunicação privada com a(o)(s) ré(u)(s). O requerimento foi deferido pel(a) MM(a). Juiz(a) que determinou que todos saíssem da sala. Ato contínuo, após a comunicação do réu e sua Defensora, foi(ram) feito(s) o(s) interrogatório(s) da(o)(s) ré(u)(s) Everton Aparecido Garcia (início de vídeo diverso e próprio).

O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) pelo sistema Microsoft Teams, informando-se os presentes sobre as gravações e com os tempos de gravação indicados no formato (Horas:Minutos:Segundos) em cada depoimento presente neste termo ou indicados por vídeos próprios.

Ao final, pelas partes, foi dito que não haviam requerimentos de diligências a serem apresentados e/ou provas a serem produzidas. Sendo assim, deliberou o(a) MM(a). Juiz(a): "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução e determino às partes que apresentem suas alegações finais.". Dada a palavra ao Ministério Público e a Defesa, suas alegações finais orais foram gravadas pelo sistema Microsoft Teams e armazenadas no sistema SAJ junto com o interrogatório colhido em audiência.

Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra EVERTON APARECIDO GARCIA, qualificado. Narrou a denúncia que, no dia 17 de março de 2019, por volta das 17h48min, na Praça David Daronco, nesta comarca, nas imediações do "Ginásio Sérgio Dias", local onde se realizam espetáculos e diversões de qualquer natureza, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 05 (cinco) cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso bruto conjunto de 4,0g (quatro gramas), droga causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, posteriormente, revogada (fls. 64/70).

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado pleiteou a rejeição da denúncia. Não arrolou testemunhas (fls. 91/94).

A denúncia foi recebida em 24/03/2020 (fl. 100).

Em audiência de instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas e interrogado o acusado.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado.

Por sua vez, a Defesa pugnou por sua absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 e requereu a fixação da pena no mínimo legal, ressaltando sua primariedade.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos

processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), auto de constatação preliminar (fl. 9), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 50/52), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a despeito de a ter negado em interrogatório, sob a alegação de que as drogas se destinavam ao mero consumo pessoal. Admitiu, porém, que o acontecimento se deu próximo a um ginásio e que havia crianças e outras pessoas no local.

Com efeito, ouvido em juízo, ratificando o depoimento prestado na fase inquisitorial, o policial militar Fábio Alexandre André relatou que possuíam informações de que o acusado estava praticando o tráfico de drogas no local dos fatos; em patrulhamento, avistaram um veículo VW/Gol, cor preta, modelo “quadrado”, parar e receber algo do acusado, que por sua vez entregou alguma coisa para o condutor do aludido veículo; imediatamente foram realizar abordagem, mas o VW/Gol evadiu-se, no entanto, abordaram o réu e com ele foram encontradas cinco cápsulas plásticas contendo cocaína e R\$40,00 (quarenta reais) em dinheiro trocado e ainda apreenderam o aparelho celular do increpado; o abordado não aparentava estar drogado; e nenhum objeto para consumo foi encontrado; local palco frequente de tráfico; foi próximo a um ginásio e havia pessoas no local; trata-se de um local movimentado; o réu já era conhecido por tráfico, embora tenha negado.

A testemunha Paulo Roberto Coelho Jacinto, também policial, no inquérito, prestou depoimento no mesmo sentido. Embora sob o crivo do contraditório tenha dito não se recordar dos fatos, tal não infirma o detalhado, coerente e seguro relato prestado pelo outro miliciano.

Nada nos autos aponta no sentido de que os deponentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da circunstância de se cuidar de policiais militares. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

As drogas não se destinavam ao consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06. Afinal, foram apreendidos entorpecentes de alto potencial ofensivo (cocaína), em quantidade não desprezível. Além disso, as drogas encontravam-se individualmente embaladas, prontas para a venda e foi apreendido dinheiro trocado, circunstância típica de transações comerciais, em que o troco se faz necessário. Não bastasse, o indivíduo não aparentou estar drogado como um mero consumidor ali presente, até porque nenhum objeto para o consumo foi achado, demais de os policiais terem recebido notícias de que o réu estava praticando tráfico, o que se confirmou ao presenciarem a troca de itens entre ele e pessoa a bordo de um veículo, nos instantes que precederem a abordagem, a qual se deu em local palco frequente deste tipo de infração penal. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela concomitante condição de usuários regulares de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), trouxe consigo drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie.

Bons antecedentes. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, não integrantes de sua estrutura, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, serão sopesadas na terceira fase da dosimetria, para evitar o bis in idem. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, nenhuma circunstância valorada negativamente, fixo as penas-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, as mantenho.

Na terceira fase, presente a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, não havendo majorantes, reduzo as penas em 1/3, para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Reconheço, ainda, a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 (infração cometida nas imediações de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza), conforme relatado pela primeira testemunha ouvida e confirmado pelo documento de fl. 47, e as aumento em 1/6, concretizando-as em 3 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Trata-se de agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa. É o que se infere de seu histórico criminal (fls. 132/133). Considerando que não ostenta nenhuma passagem policial prévia, mas que a traficância envolveu cocaína, droga cuja natureza ostenta alto potencial lesivo à saúde, embora apreendida em quantidade reduzida (4g), emprego, em proporção intermediária, a fração redutora de 1/3 para a causa de diminuição de pena em apreço.

Verifico que a narcotraficância ocorreu próxima a ginásio em funcionamento, havendo fluxo de crianças e outros indivíduos nas imediações, de sorte que a prática criminosa e a disseminação das drogas foi facilitada pela aglomeração de pessoas, pelo que caracterizada a hipótese prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, o qual não exige que a mercancia se dirija aos frequentadores do estabelecimento, observado o seu caráter objetivo e a inexistência de previsão legal nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça endossa a posição:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. AFASTAMENTO. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos

locais, ou mesmo de o comércio visava a atingir os estudantes, as pessoas hospitalizadas, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, o paciente foi flagrado praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações dos estabelecimentos Unidade de Saúde da Família - Dr. Luís Spina e do CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

2. O Colegiado estadual afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, o que não configura manifesto constrangimento ilegal, porquanto devidamente fundamentada a negativa do benefício com fulcro no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, que determina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 5 anos e 10 meses de reclusão, não é possível a pretendida substituição.

4. Mantido o regime inicial fechado pelo Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso concreto, em especial a quantidade e natureza da droga envolvida na empreitada criminosa (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006), não há constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 359.088/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 17/10/2016.)

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será aberto, ante o patamar de pena corporal aplicado (art. 33, § 2º, "c", CP).

Embora trate-se de crime equiparado ao hediondo, o art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, afigura-se inconstitucional, por desrespeito ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e ao princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF) (HC 111.840, STF).

Inaplicável o art. 387, § 2º, do CPP, por ter o réu respondido o processo em liberdade.

Considerando o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais, em sua maioria favoráveis, concedo, com supedâneo no art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual período da condenação, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, de acordo com as aptidões condenado e de forma a não prejudicar a sua jornada normal de trabalho, observando-se finalmente para o cumprimento da pena substitutiva, o disposto no § 4º do artigo 46 do Código Penal, e prestação pecuniária, no importe de 10 (dez) salários-mínimos, cuja destinação será definida na execução.

Não é cabível a suspensão condicional da pena, porquanto concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na linha do art. 77, III, do CP.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu EVERTON APARECIDO GARCIA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, substituída a pena corporal por 2 (duas)

restritivas de direitos, nomeadamente, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos, nos termos da fundamentação retro.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pela infração, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Defiro o recurso em liberdade, ao passo que desnecessária a segregação cautelar, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, enquanto produto do crime (art. 91, II, "b", CP c/c art. 122, CPP); f) proceda-se na forma do art. 123 do CPP e das normas da e.

Corregedoria quanto aos demais bens apreendidos; g) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; h) oportunamente dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016)."

A sentença foi lida aos presentes que saíram devidamente intimados. Pela(o) ré(u) e pelo(a) o(a)(s) Advogado(a)(s) de Defesa foi interposto recurso de apelação, neste ato, recebido pelo(a) MM(a). Juiz(a), saindo a Defesa intimada para apresentar razões no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal. Ao final, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas necessárias e homenagens deste juízo. O Ministério Público manifestou desejo de não recorrer, operando-se o trânsito em julgado para a acusação nesta data, valendo a presente como certidão.

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema e juntados aos autos no sistema SAJ. NADA MAIS, para constar lavrei o presente termo de audiência. Dispensada a assinatura das partes por se tratar de processo eletrônico. Eu THAUANN PINHEIRO SANTIAGO, Escrevente Técnico Judiciário, M373043, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA